

정기상여금에 관한 ‘지급일 재직 조건’의 위법성

○ 대법원 2017. 9. 26. 선고 2016다238120 판결; 대법원 2017. 9. 26.
선고 2017다232020 판결

권오성(성신여자대학교 법과대학)

[판결 요지]

이 사건 상여금은 지급기준일에 재직 중인 근로자에게 지급하는 임금으로서 소정근로에 대한 대가의 성질을 가지는 것이라고 보기 어려울 뿐 아니라 근로자가 임의의 날에 연장·야간·휴일 근로를 제공하는 시점에서 그 지급조건이 성취될지 여부도 불확실하므로, 통상임금에서 요구되는 고정성이 결여되었다고 볼 수 있고, 따라서 통상임금에 포함된다고 할 수 없다.

대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결은 지급일 재직 조건이 붙은 수당의 통상임금성에 관하여 “근로자가 소정근로를 했는지 여부와는 관계없이 지급일 기타 특정 시점에 재직 중인 근로자에게만 지급하기로 정해져 있는 임금은 그 특정 시점에 재직 중일 것이 임금을 지급받을 수 있는 자격요건이 된다. 그러한 임금은 기왕에 근로를 제공했던 사람이라도 특정 시점에 재직하지 않는 사람에게는 지급하지 아니하는 반면, 그 특정 시점에 재직하는 사람에게는 기왕의 근로 제공 내용을 묻지 아니하고 모두 이를 지급하는 것이 일반적이다. 그와 같은 조건으로 지급되는 임금이라면, 그 임금은 이른바 ‘소정근로’에 대한 대가의 성질을 가지는 것이라고 보기 어려울 뿐 아니라 근로자가 임의의 날에 근로를 제공하더라도 그 특정 시점이 도래하기 전에 퇴직하면 당해 임금을 전혀 지급받지 못하여 근로자가 임의의 날에 연장·야간·휴일 근로를 제공하는 시점에서 그 지급조건이 성취될지 여부는 불확실하므로, 고정성도 결여한 것으로 보아야 한다.”고 판시하였다. 이후 다수의 하급

심 재판에서 ‘지급일 재직 조건’이 붙은 정기상여금이 통상임금에 해당하는지 여부가 다투어졌다. 재직자 조건이 있음을 이유로 정기상여금이나 매월 지급되는 상여수당 등의 통상임금성을 부정한 판결이 다수이나,¹⁾ 몇몇 하급심 판결에서는 정기상여금 지급일에 재직하는 자를 지급대상으로 삼아 그 전에 퇴직한 근로자는 지급받지 못하는 경우는 매우 소수인 퇴직자에 한정되기 때문에 고정성을 부인할 수 없다거나, 정기상여금은 후불제적 임금으로 지급일 이전 퇴직자에게는 일할계산해서 주는 것이 타당하므로 재직일 조건이 달렸다고 해서 재직일 전 퇴직자에게 정기상여금을 하나도 주지 않는 것은 위법하고 따라서 재직일 조건이 달린 정기상여금도 고정성이 있다는 이유로 재직자 조건이 있음에도 불구하고 정기상여금 등의 통상임금성을 긍정하였다.²⁾

이러한 상황에서 대법원은 2017. 9. 26. 선고된 2개의 판결에서 지급일 현재 재직하고 있는 근로자에게만 지급되는 정기상여금은 근로자가 근로를 제공하더라도 지급일 전에 퇴직하면 당해 정기상여금을 전혀 지급받지 못하므로 소정근로에 대한 대가의 성질을 가지는 것이라고 보기 어려울 뿐 아니라 고정성도 인정되지 않아 통상임금에 해당하지 않는다는 취지로 판단하였다. 이들 판결은 2013년의 전원합의체 판결에서 제시한 고정성에 관한 판단기준을 정기상여금에도 그대로 적용한 것으로 보이는바, 과연 설·추석상여금, 하기휴가비, 귀성여비, 김장보너스, 선물비 등 근로자에게 재정적 수요가 필요한 ‘특정한 시기’에 소정근로의 제공 여부를 묻지 않고 재직여부라는 우연한 상황에 따라 그 전액의 지급여부가 결정되는 수당과 정기상여금을 규범적으로 동일하게 취급하는 것이 정당한가 하는 의문이 든다. 무엇보다 이들 판결은 소정근로의 대가인 임금은 그 지급기일 이전에 퇴직하더라도 소정근로에 상응하는 부분만큼

1) 서울중앙지방법원 2016. 1. 29. 선고 2012가합87787 판결(서울메트로 사건); 서울중앙지방법원 2016. 6. 23. 선고 2012가합88902 판결(대우조선해양 사건); 서울고등법원 2016. 10. 12. 선고 2015나25909 판결(서울특별시도시철도공사 사건); 서울고등법원 2017. 5. 12. 선고 2016나2039352 판결(중소기업은행 사건) 등.

2) 부산지방법원 2014. 10. 10. 선고 2011가합27496 판결(르노삼성자동차 사건); 서울북부지방법원 2015. 7. 15. 선고 2014가합20572 판결(삼양교통 사건) 등.

은 당연히 지급해야 한다는 일반적인 이해와는 반대로, 지급기일 이전에 퇴직하는 경우에는 지급되지 않는다는 조건이 붙은 금원(그러한 조건의 유효성에 관한 판단을 생략한 채)은 소정근로의 대가가 아니라고 판단하였는바, 이는 문제가 되는 금원의 법적 성격이 무엇인지를 살피는 것이 아니라, 그러한 금원의 지급조건을 가지고 그 금원의 법적 성격이 무엇인지를 결정하는 방식으로 역전(逆轉)된 논리를 보여 준다.

기본적으로 우리나라에서 기본급에 고정된 지급률을 곱하여 산정된 고정급 형태의 정기상여금은 실질적으로는 월소정근로에 대응하는 기본급을 수개월 누적하여 후불함에 다름 아니라고 생각한다. 현행 근로기준법은 상여금에 대한 정의규정을 두고 있지 않고, 다만 근로기준법시행령 제23조 제3호에서 임시로 지급하는 임금 등의 하나로 “1개월을 초과하는 기간에 걸친 사유에 따라 산정되는 장려금, 능률수당 또는 상여금”을 규정하고 있을 뿐이다. 대법원은 1981. 11. 24. 선고 81다카174 판결에서 상여금이 정기적으로 지급되고 그 지급액이 확정되어 있다면 이는 당시의 근로기준법 제36조 제2항 단서 및 동법시행령 제18조에 규정된 임시지급의 임금과 같이 볼 수 없고 정기일 지급 임금의 성질을 띤 것이라고 보아야 하므로, 상여금지급기간 만료 전에 퇴직한 근로자라도 특단의 사정이 없는 한 이미 근무한 기간에 해당하는 상여금은 근로의 대가로서 청구할 수 있다는 취지로 판단하였다. 참고로 일본의 행정해석은 노동기준법의 제정 초기부터 정기적으로 지급되고 또한 지급액이 확정되어 있는 것은 상여로 보지 않고 정기 또는 임시로 근로자의 근무성적에 의하여 지급되어 지급액이 확정되어 있지 않은 것만을 상여로 보는 입장이었고,³⁾ 이러한 입장은 현재에도 유효하게 견지되고 있다.⁴⁾ 일본의 경우 지

3) 1947(昭22).9.13, 發基 17号:『【法第二四條關係】賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、その支給額が予め確定されてゐないものを云ふこと。定期的に支給され、且その支給額が確定してゐるものは、名称の如何にかゝらず、これを賞与とはみなさないこと。従つて、かゝるもので施行規則第八條に該当しないものは、法第二四條第二項の規定により毎月支拂われなければならないこと。』(밑줄은 필자)

4) 일본 후생노동성 근로기준국이 2014년 발간한 노동기준법해석총람에도 위 행정해석이 여전히 실려 있다. 厚生労働省労働基準局編, 『労働基準法解釋總覽』

금액이 확정되어 있지 않은 본래의 의미의 상여는 정기일지급의 원칙이 적용되지 않으나,⁵⁾ 지급액이 확정되어 있는 경우에는 그 명칭의 여하에 관계없이 이를 상여로 보지 않으며, 따라서 이러한 금원은 일본 노동기준법 제24조 제2항의 규정에 따라 매월 지불하여야 한다고 해석된다.

따라서, 근로기준법시행령 제23조 제3호에서 임금정기일지급원칙의 예외로 규정하는 ‘상여금’은 1개월을 초과하는 기간에 걸쳐 기업의 경영실적, 근로자의 근무성적 등의 사유에 따라 산정하여 지급되는, 따라서 본질적으로 그 지급금액이 가변적인 금원만을 의미한다. 따라서 ‘고정금’으로 지급되는 정기상여금은 당연히 소정근로의 대가이고 엄격한 의미에서 상여금(Bonus 또는 一時金)의 개념에 포섭되지 않는다. 그러므로 고정금 형태의 정기상여금은 ‘상여금’ 자체가 아니며, 따라서 수개월마다 정기적, 고정적으로 지급되는 정기상여금 지급약정은 그 자체가 임금정기일지급의 원칙에 위반하여 무효이고, 다만 무효행위의 전환의 법리에 따라 정기상여금 명목의 금원을 매월 정가지급일에 안분하여 지급하는 계약으로 인정될 수 있을 뿐이다.

이와 같이 소정근로의 대가로 지급되는 성질을 지니고 있음이 분명한 고정금의 정기상여금⁶⁾은 그 지급대상기간의 중도에 퇴직한 근로자에 대해서 실제 근무일수에 비례한 만큼의 일부 지급이 당연히 이루어져야 한다.⁷⁾ 따라서 일부 사업장의 단체협약 등에 ‘지급일 재직 조건’과 함께 일할지급에 관한 규정이 있는 경우, 이러한 일할지급 규정은 확인적 의미를 갖는다고 보아야 할 것이며, 일할지급에 관한 명문의 규정이 없는 사업장의 경우에도 정기상여금의 지급일 이전에 퇴사한 근로자는 자신이 제공한 근로기간에 상응하는 금액의 정기상여금을 청구할 수 있다고 보아야 할 것이다.

(改訂15版), 労働調査會, 2014(平26), 258쪽.

5) 片岡 昇(송강직 역), 『노동법』, 삼지원, 1995, 485쪽.

6) 물론, 상여금이 분기 또는 1년의 소정근로에 대하여 지급하기로 한 분기급 또는 연급(연봉)으로서의 성질을 가지는 것은 아니라는 견해도 있다. 대표적으로, 하경호, 『임금법제론』, 신조사, 2013, 87쪽.

7) 김도형, “통상임금의 고정성 징표에 대한 검토”, 해밀 이슈페이퍼 제2호, 2016. 1, 7면.

그러므로 고정급 형태의 정기상여금에 부가된 지급일 재직 조건이 정기상여금의 전액을 지급하지 않는다는 취지라면, 이러한 조건은 임금정기일지급의 원칙,⁸⁾ 임금채권의 사전포기의 제한⁹⁾, 강제근로의 금지 등 근로기준법의 명문규정 및 공서양속에 반하여 무효이다.

한편 정기상여금 지급약정에 부가된 지급일 재직 조건은 정기상여금이라는 임금채권의 발생에 관한 계약의 기본적인 내용을 구성하는 것이 아니라 그러한 계약의 조건, 즉 부관(附款)에 불과하므로, 정기상여금에 붙은 지급일 재직 조건이 무효인 경우에는 기본적인 정기상여금 지급약정은 조건이 없는 법률행위로 존재하게 된다. 따라서 지급일 이전에 퇴사한 근로자도 유효하게 정기상여금에 관한 임금채권을 행사할 수 있어야 하며, 다만 지급일 재직 조건은 퇴사일의 다음 날부터 지급일 내지 정기상여금의 산정기간의 종일(終日)까지의 기간, 즉 퇴사로 인하여 근로를 제공하지 않는 기간에 상응하는 부분의 정기상여금을 비례적으로 감축한다는 취지로 제한적으로 해석될 수는 있을 것이다.

대사판결들은 정기상여금에 관한 ‘지급일 재직 조건’의 유효성에 관한 판단을 생략한 채 이러한 조건의 유효함을 전제로 정기상여금의 통상임금성을 부정하였다는 점에서 동의하기 어렵다.

8) 임종률 교수는 정기일지급의 원칙과 관련한 부분에서 “수개월에 1회씩 지급되는 상여금의 지급 기일 전에 근로자가 퇴직한 경우 그 상여금을 지급해야 하는지가 문제될 수 있다. 그러나 상여금이 근로의 대가로서의 성격을 가지고 있는 이상 지급기일 전에 퇴직하더라도 그 산정기간에 실제 근무한 일수나 그 밖의 산정기준에 따라 상여금을 지급해야 한다. 따라서 상여금 지급기일에 재직할 것을 그 지급조건으로 정하는 것은 원칙적으로 무효라고 보아야 할 것이다.”라고 서술하고 있다. 임종률, 『노동법』(제14판), 박영사, 2016, 418쪽.

9) “모든 임금은 근로의 대가로 지급되는 것이고, 상여금 또는 수당의 임금성이 긍정되는 이상 지급기준일 이전에 퇴직한 근로자에게도 퇴직시점까지의 근로의 대가는 해당 기간의 근로제공일수 비율에 따라 지급되어야 한다. 이러한 점에서 재직자임금지급규정은 근로자가 근로제공의 대가로 지급받아야 할 임금을 사전에 포기토록 하는 약정으로 무효”라는 지적으로 김기선, “재직 중인 자에게만 지급되는 임금도 통상임금이다”, 『노동판례리뷰 2014』, 한국노동연구원, 2015, 64쪽.